

0001298-89.2017.8.26.0306

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA CASTRO ANDRADE SILVA

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... fez a ocorrência de associação ao tráfico. O depoente se recorda de ter sido abordado por uma senhora de Roseli Aparecida dizendo que o filho dela de 15 anos estaria envolvido com drogas e que a droga pertencia ao Felipe e que seu filho estava guardando. Declara que haviam muitas denúncias com relação a casa do Anderson com relação ao tráfico ilícito de entorpecentes. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

1ª Vara

Av. Monsenhor Ângelo Angioni, nº 1000, José Bonifacio-SP - cep 15200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001298-89.2017.8.26.0306 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001298-89.2017.8.26.0306

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu

Felipe da Silva Gomes, Valdinei Marcos Dias Vale, JULIANO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, JUNIOR JOSE RAMOS e ANDERSON JUNIOR DA SILVA FERREIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA CASTRO ANDRADE

ANDERSON JÚNIOR DA SILVA FERREIRA (fl. 393), FELIPE DA SILVA GOMES (fl. 56), JULIANO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA (fl. 71), JÚNIOR JOSE RAMOS (fl. 78) e VALDINEI MARCOS DIAS VALE (fl. 63) foram denunciados como incurso no art. 33, caput e art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006 (fls. 350/353).

Isso porque, segundo consta, em 17 de maio de 2017, às 12h20min, na Rua Joaquim Pinto de Mendonça, 1048, CDHU Ana Sérgio de Matos, na cidade de Ubarana/SP, os acusados praticavam o ato de trazer consigo, para entrega a consumo 16,39g (dezesesseis gramas e trinta e nove centigramas), da substância entorpecente conhecida por Maconha, contendo Tetrahydrocannabinol (THC), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também que, no dia 17 de maio de 2017, às 12h20min, na Rua Joaquim Pinto de Mendonça, 1048, CDHU Ana Sérgio de Matos, na cidade de Ubarana/SP, os réus, agindo em concurso e com unidade de desígnios, associaram-se para o fim de praticar reiteradamente ou não o crime de tráfico de drogas.

Foi apresentado o seguinte rol de testemunhas: PM Ronie Carlos de Araújo fls. 4/5 e

171), PM Edson de Souza Santos (fls. 7/8), João Carlos Martins (fls. 181). Recebida a denúncia (fls. 581/583), os acusados foram notificados (fls. 367, 562, 363, 361, 365), citados pessoalmente (fls. 608, 562, 614, 609 e 668 ) e apresentaram defesa prévia (fls. 373/389; 572/574; 499/503; 398/407 e 525/528 ), por defensores nomeados (fls. 390; 568; 468; 408 e 516), negando as práticas dos delitos e pedindo absolvição e arrolando a mesma testemunha de Acusação, João Carlos Martins, e, pelo réu Anderson, a seguinte testemunha de Defesa : Rosângela de Almeida.

Foi realizada audiência de instrução.

As partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pediu absolvição por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

A autoria e materialidade dos fatos restaram indiciariamente demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 32/36; 142/143), termos de declarações, depoimentos e interrogatório (fls. 4/5; 7/24; 171; 180/181; 165/168; 195; 197), auto de apreensão e entrega (fls. 37/38; 144/145), relatório final (fls. 183/188) e laudos periciais (fls. 40/41; 172/175 e 420/424).

Por sua vez, o contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório dá parcial respaldo à acusação.

Conforme a denúncia:

Apurou-se que, após uma “notitia criminis” de que os denunciados receberam uma porção grande de drogas entregue por um moto taxista, e que eles no interior da residência cortaram o material e separaram em porções menores; policiais militares dirigiram-se até o endereço supracitado e adentraram a residência encontrando ANDERSON JÚNIOR DA SILVA FERREIRA e VALDINEI MARCOS DIAS VALE que fugiram para o interior da casa.

No interior da casa estavam ANDERSON JÚNIOR DA SILVA FERREIRA vulgo “DEDÉ”, qualificado a fls.09/11, FELIPE DA SILVA GOMES vulgo “TAT00”, qualificado a fls. 12/14, VALDINEI MARCOS DIAS VALE qualificado a fls.15/18, JULIANO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, qualificado a fls. 19/21, JUNIOR JOSÉ RAMOS, qualificado a fls.22/24 e em revista pelo imóvel encontraram no interior de um bichinho de pelúcia com zíper, 05 (cinco) porções de maconha, em um quarto da casa encontraram mais 03 (três) porções de maconha e neste momento ANDERSON JÚNIOR DA SILVA FERREIRA vulgo “DEDÉ”, qualificado a fls.09/11 e FELIPE DA SILVA GOMES vulgo “TAT00”, qualificado a fls. 12/14, disseram que o conteúdo encontrado era de uso pessoal pois eles residiam naquele local.

Ato contínuo, os policiais lograram êxito em localizar e apreender papel filme com cheiro e vestígios de maconha, a embalagem do papel filme e uma faca grande de cozinha também com cheiro e vestígios de maconha.

Auto de Exibição e Apreensão acostado a fls. 37/38.

Laudo de Constatação n.º 215694/2017 acostado a fls. 40/41.

Exame Toxicológico Definitivo n° 216.285/2017 acostado a fls.172/175

Foram apreendidos: uma caixa de embalagem de filme de PVC transparente da marca Pratsy; um pedaço de plástico filme de PVC transparente; uma faca de cozinha, da marca Tramontina, com cabo de madeira, com vestígios aparentando ser de substância entorpecente; R\$4,00 em cédulas e R\$5,25 em moedas e 17,450 gramas de maconha acondicionadas em 8 invólucros plásticos.

O laudo de constatação, de exame químico-toxicológico, apontou resultado positivo para: os canabinóides componentes da Cannabis sativa L. (maconha), nas amostras colhidas de porções de fragmentos vegetais, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos com massa líquida de 16,39 gramas (fls.40/41).

O laudo de exame químico-toxicológico definitivo, apontou resultado positivo para: tetrahydrocannabinol – THC nas amostras colhidas de invólucro plástico transparente cujo interior continha uma amostra de fragmentos vegetais, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos com massa líquida de 16, 39gramas (fls.172/175). O THC é um canabinóide comumente presente em partes da planta Cannabis sativa L. (maconha)

O laudo de exame químico-toxicológico definitivo, realizado na faca e nas embalagens de PVC, detectou a presença da tetrahydrocannabinol – THC na faca e no fragmento de plástico do tipo filme. Na embalagem de papelão de filme PVC, da marca Pratsy não foi detectada a presença de substâncias (fls.423/424).

O laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 421/422 apontou resultado positivo para: tetrahydrocannabinol – THC nas amostras colhidas de 18 porções de fragmentos vegetais acondicionadas em invólucros plásticos e um cigarro artesanal, parcialmente queimado, confeccionado em papel e envolvendo fragmentos vegetais, com massa líquida de 87,54 gramas (fls. 421/422)

A testemunha PM Ronie Carlos de Araújo relatou que receberam uma denúncia através do telefone 190 de que havia fracionamento, embalagem e tráfico de entorpecentes no endereço relacionado com os presentes autos. Declara que a denúncia era que um mototaxista havia deixado na casa do Anderson dois tijolos de maconha. Declara que na referida residência havia uma lona preta no portão para impossibilitar ou dificultar a visibilidade do que acontecia no interior do imóvel. Pegaram de pronto a viatura e se dirigiram ao local indicado, onde foi notado uma movimentação suspeita e Valdinei imediatamente empreendeu fuga ao avistar a viatura da polícia militar, correndo para dentro do banheiro da residência e jogando algo no vaso sanitário e dando descarga em seguida. Declara que pularam o muro, desobstruindo a entrada da residência e abordaram os elementos, seguido de uma revista pessoal e individual neles. Declara que dentro da casa foi encontrada uma faca com resquícios de maconha e filme plástico de PVC. Declara que a mulher de Anderson tinha um bebê na época e que foi encontrado um ursinho de pelúcia, contendo em seu interior cinco pedaços grandes de maconha embalados no filme PVC e posteriormente foi encontrado uma bolsa preta e em seu interior mais três pedaços de maconha. Declara que diante de todas as evidências encontradas os elementos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia, onde o Delegado fez a ocorrência de associação ao tráfico. O depoente se recorda de ter sido abordado por uma senhora de Roseli Aparecida dizendo que o filho dela de 15 anos estaria envolvido com drogas e que a droga pertencia ao Felipe e que seu filho estava guardando. Declara que haviam muitas denúncias com relação a casa do Anderson com relação ao tráfico ilícito de entorpecentes. Declara que a presença de todos que foram presos nesta ocorrência era constante naquele imóvel. Aos questionamentos feitos pela Advogada de Defesa de Felipe respondeu que o motivo de abordarem o local sem a expedição de um Mandado de Busca e Apreensão e porque a denúncia era muito ardente e dizia que a droga havia sido entregue naquele momento, então acharam importante fazer a abordagem. Declara que não havia tempo hábil de pedir a expedição de mandado. Declara que quando chegaram na residência havia elementos para afirmar que os indivíduos estavam naquele momento fracionando, embalando e prontos para iniciar a distribuição para os pontos de venda. Declara que o denunciante afirmou ter visto que os indivíduos estavam naquele momento fracionando, embalando e prontos para iniciar a distribuição para os pontos de venda. Declara que os fatos narrados não foram de forma alguma frutos de sua imaginação. Declara que a informação do denunciante era fidedigna e com riqueza de detalhes. Quem morava na casa era o Anderson. Declara que Anderson alegou que todos os entorpecentes encontrados na casa eram seus. Após a denúncia feita não havia mais tempo hábil para nada, senão a diligência seria frustrada. Declara que além da denúncia anônima o que motivou a diligência foi a movimentação suspeita no local. Declara que Junior era bem contumaz no tráfico de entorpecentes. O moto-taxista não foi encontrado para dar a sua versão ou depoimento.

A testemunha PM Edson de Souza Santos narrou que houve uma denúncia anônima de tráfico ilícito de entorpecentes no endereço do local dos fatos, onde denunciava que um mototaxista havia deixado dois tabletes de maconha na residência, e que a mesma era posteriormente fracionada e vendida. Declara que se deslocaram até o local, onde nenhuma criança ou adolescente foi encontrado, porém ao encostarem no muro para ouvirem a conversa, que estava bastante alta no local devido a uma aglomeração de pessoas, aí avistaram cinco pessoas, que eram Anderson, Felipe, Valdinei, Junior e Juliano. Declara que ao avistar os policiais Valdinei entrou correndo em sua residência e os policiais adentraram em seu encalço. Ao abordarem Valdinei o mesmo estava dando descarga no vaso sanitário. Declara que o trouxeram

para fora da residência e submeteram os cinco abordados a uma revista pessoal. Declara que nada foi localizado com os mesmos. Deu-se início então a busca domiciliar na residência de Valdir. Na cozinha do imóvel foi encontrada uma faca que aparentava ter sido utilizada para o fracionamento de tabletes de maconha, ao lado dela um rolo de papel filme já utilizado, bem como pedaços de PVC. Declara que foi encontrado também na cozinha um urso de pelúcia e no seu interior havia cinco pedaços cortados de maconha embalados com o filme de PVC. Declara que em um dos quartos foi encontrado uma mochila preta contendo em seu interior cinco pedaços de maconha também embalados, bem como R\$ 9,00 em espécie. Diante de todas as evidências encontradas foi dada voz de prisão aos acusados, que foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Todos já haviam sido envolvidos em ocorrências policiais com tráfico de entorpecentes. Com relação a faca apreendida declara que estava exposta em cima da mesa, juntamente com o pedaço de PVC. O depoente confirma que já havia recebido denúncias de tráfico de entorpecentes com relação aos cinco envolvidos. Tem conhecimento que Anderson já é usuário de entorpecentes desde a sua infância e adolescência. Quando subiu no muro e avistou os elementos eles estavam aglomerados no local e somente Valdinei saiu correndo. Declara que Anderson não estava com a faca na mão e que na busca pessoal não foi nada encontrado com nenhum deles. A diligência foi acionada via denúncia telefone 190. Declara que a casa fica na frente do genitor de Anderson e que na casa dele já havia sido feito apreensão de drogas anteriormente, porém no local da diligência não. Declara que antes da abordagem e apreensão o local era desconhecido tanto da polícia civil como da polícia militar. Declara que a entrada no imóvel para busca domiciliar foi autorizada por Edson José Ferreira de Jesus. Declara que não se recorda se Edson morava no imóvel ou se era somente proprietário. Declara que a entrada no imóvel foi imediatamente após a atitude suspeita de Valdinei, que empreendeu fuga após avistar a polícia militar. Declara que Felipe é conhecido nos meios policiais por ser usuário de entorpecentes. Na data da ocorrência não foi avistado o Juliano comercializando entorpecentes. Declara que em outras datas já abordou Juliano entregando drogas para terceiros, porém a pessoa que recebeu a droga disse que era para uso próprio. Declara que no dia da ocorrência nenhum comprador foi preso no local. Não houve campana prévia no local antes da apreensão e prisão dos elementos. Conhece a pessoa de Junior através de várias ocorrências de tráfico de entorpecentes, desde quando o mesmo era menor e também depois que atingiu a maioridade. Declara que não houve expedição de Mandado de Busca e Apreensão para o endereço diligenciado.

A testemunha, João Carlos Martins afirmou que é irmão de Valdir Felício Martins. Declara não ter conhecimento se Valdinei tem envolvimento do drogas. Aos questionamento feitos pela Advogada de Defesa de Anderson respondeu que não tem conhecimento que um rapaz chamado Felipe dormia na varanda de Anderson. Declara que conhece Anderson e que o mesmo sempre trabalhou prestando serviços para o depoente. Declara que não tinha conhecimento que Anderson era traficante de entorpecentes. Declara nunca ter visto nenhum movimento estranho ou suspeito na frente da casa dele. Aos questionamentos feitos pelo Advogado de Defesa de Juliano respondeu que é Fiscal de Ruas na cidade de Ubarana há trinta anos e conhece todas as ruas da cidade. Declara que nunca recebeu reclamação ou denúncia referente a drogas. Aos questionamento feitos pela Advogada de Defesa de Junior respondeu que conhece Junior José Ramos. Declara que tem conhecimento que o mesmo trabalha e que é pessoa idônea. Não se recorda se houve algum comentário na cidade de Ubarana com relação ao tráfico de drogas envolvendo a pessoa de Junior. Aos questionamentos feitos pela Advogada de Defesa de Valdinei respondeu que Valdinei já chegou a trabalhar algumas vezes com o depoente. Confirma que no dia dos fatos Valdinei estava trabalhando com ele.

A testemunha Rosângela de Almeida disse que não se recorda de nada sobre essa ocorrência. Pela Advogada de Defesa de Anderson respondeu que não tem conhecimento que ele traficava drogas, somente tinha conhecimento que ele era usuário. Declara que nunca viu nenhum movimento suspeito na frente da casa dele. Não tem conhecimento se Felipe foi expulso da casa de sua mãe. Também não tem conhecimento se Felipe dormia na varanda de Anderson.

Em seu interrogatório, o acusado Anderson negou a acusação, afirmando que não estava preparando drogas para a venda. Declara que é usuário de entorpecentes. Declara ser tratorista. Declara que Felipe estava morando com o depoente. Declara que a mãe de Felipe o expulsou de casa e que na data da ocorrência ele e Felipe estavam consumindo entorpecentes. Declara que o entorpecente encontrado no urso de pelúcia foi escondido por Felipe à sua revelia. Declara que franqueou a entrada de sua residência para revista pelos policiais militares. Declara que a droga foi comprada por Felipe e que era para uso. Declara não comercializar drogas.

Em seu interrogatório, o acusado Valdinei negou a acusação, afirmando que estava saindo da casa de Anderson quando a viatura chegou. Declara que jogou o baseado que estava consumindo no vaso sanitário de deu descarga. Nada do que foi apreendido era seu.

Em seu interrogatório, o acusado Juliano negou a acusação, afirmando que nunca houve tráfico de entorpecentes, que a droga era para uso. Declara ser proprietário de um Lava Jato e que na época dos fatos trabalhava em uma cerâmica. Com relação a droga que foi encontrada e apreendida disse que era do Felipe. Declara que nunca foi condenado pela Justiça.

Diante da revelia dos acusados Felipe e Júnior, seus interrogatórios ficaram prejudicados.

Diante das narrativas oferecidas, concluo que o tráfico ficou efetivamente caracterizado, essencialmente, pelos fundamentos abaixo.

Após o recebimento de uma denúncia anônima de que teria chegado grande quantidade de droga no interior da residência onde os acusados estavam, os policiais dirigiram-se até o local e encontraram Anderson e Valdinei que, quando os avistaram, evadiram-se para o interior da casa. Além deles, estavam na residência Felipe, Juliano e Júnior e ao revistarem a casa, os policiais encontraram porções de maconha escondidas em um ursinho de pelúcia e em um dos quartos.

Os acusados Anderson e Felipe admitiram que eram usuários e que as drogas eram deles, que moravam no local. Também foram apreendidos dinheiro, papel filme com cheiro e vestígios de maconha, além de uma faca com os mesmos sinais.

Pela quantidade, variedade e modo de acondicionamento das drogas e pelos locais onde foram encontradas, não é possível afirmar que elas se destinavam a consumo pessoal (art. 28, §2º, da Lei 11.343/06).

Além disso, a apreensão de petrechos e quantia em dinheiro, somadas à confissão, corroboram a existência do tráfico.

Cabe observar que é lícito o ingresso em domicílio mediante autorização do morador ou, mesmo sem mandado judicial, se houver fundados indícios da existência de flagrante delito (art. 5º, XI, da Constituição e art. 240 do CPP). Como o tráfico, na modalidade de guardar ou ter em depósito drogas, é crime permanente, sua consumação se prolonga no tempo, de modo que o agente se encontrará em flagrante delito enquanto não cessar a permanência (art. 303 do CPC).

No caso, foi feita uma denúncia sobre recebimento de drogas no local e os acusados, que já eram conhecidos pela prática de tráfico de drogas, ao serem vistos pelos policiais, correram para a residência onde moravam, o que caracterizou situação de flagrante a legitimar a busca domiciliar. Ademais, os acusados não relataram terem sido coagidos para falar onde as drogas se encontravam, nem há indícios mínimos de que eles sofreriam represália, por eles imaginada, caso se mantivessem em silêncio. Diante disso, não houve ilicitude ou abuso apto a acarretar a ilicitude das provas obtidas:

1. Durante a realização de diligência verificar a existência de indícios de crime após o recebimento de notícia anônima circunstanciada, a guarnição policial se deslocou até o local dos fatos. O agravante, por sua vez, ao avistar a viatura policial empreendeu fuga, no que foi seguido pelos policiais até que adentrou à residência. Diante da fundada suspeita da prática de crime, os milicianos adentraram à residência e lograram apreender significativa quantidade de entorpecente.

2. "Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades

relativas ao cumprimento da medida" (RHC 99.309/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 10/8/2018). (AgRg no HC 556.588/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

II - Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no RESp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

III - A garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. Precedentes.

IV - No caso dos autos, a entrada dos policiais não decorreu de mera "atitude suspeita" dos pacientes, porquanto, conforme consignado pelo eg. Tribunal a quo, os milicianos "realizavam patrulhamento de rotina" quando "os dois adolescentes, ao verem a viatura policial, correram para dentro do lote" e "diante da atitude suspeita, entraram no lote" (fl. 278), eventos por si só suficientes para configurar as "fundadas razões" para se concluir que havia flagrante delito em andamento, bem como a autorizar o ingresso em domicílio sem autorização judicial ou consentimento. Não obstante, soma-se a essa circunstância o fato de ter havido autorização para o ingresso na residência, visto que "a irmã de um dos adolescentes autorizou a entrada dos policiais na casa" (fl. 280). Habeas corpus não conhecido. (HC 540.714/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Vale dizer ainda que o simples fato de as testemunhas serem policiais, por si só, não tem o condão de enfraquecer seus depoimentos, os quais devem ser valorados com isenção e em cotejo com os demais elementos probatórios:

Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016)

Sequer há motivo para se imaginar que os agentes ou terceiras pessoas desconhecidas pretendessem incriminar os acusados falsamente.

Por sua vez, a Defesa não conseguiu demonstrar a falibilidade dos depoimentos das testemunhas. Com efeito, não basta apenas argumentar que inexiste presunção de veracidade dos depoimentos dos policiais ou que não é possível presumir a culpa apenas porque a droga foi encontrada dentro do imóvel. É preciso ir além das teses, oferecendo-se explicação concreta para os fatos. As versões apresentadas pelos acusados precisariam ser verossímeis e não foram. Na verdade, a tese de Defesa pressupõe que a conduta dos agentes assumiu conotação abusiva ou que alguém desconhecido queria prejudicá-los, mas não há razão concreta e idônea que a sustente, pelos motivos já expostos.

Ressalte-se também que nada impede que a traficância ocorra em paralelo com o uso de drogas e/ou com o exercício de ocupação lícita, razão pela qual tais alegações não afastam a caracterização da conduta típica. Ademais, o art. 33, caput, da Lei 11.343/06 se caracteriza como tipo misto alternativo, de maneira que basta que o agente incorra em qualquer das condutas ali mencionadas, dentre elas a de ter drogas em depósito, sem autorização, como descrito na denúncia.

Em virtude da quantidade de drogas encontradas e seu modo de acondicionamento, está claro que seriam vendidas para o consumo de terceiros, daí decorrendo a origem da quantia em dinheiro consigo encontrada, sequer havendo que se cogitar de porte para consumo pessoal.

Por outro lado, para a caracterização da associação para o tráfico, é necessária a existência de vínculo com estabilidade e permanência entre os réus, além de mínima

organização e hierarquia entre eles, não bastando a mera coautoria ou colaboração eventual:

O artigo exige, para a configuração do delito, apenas a associação de duas ou mais pessoas com o fim de reiteradamente ou não praticarem os delitos do artigo 12 ou 13. Ora, poder-se-ia entender que também configuraria o crime o simples concurso de agentes, porque bastaria o entendimento de duas ou mais pessoas para a prática da conduta punível, prevista naqueles artigos para a incidência no delito agora comentado, em virtude da cláusula 'reiteradamente ou não'.

Parece-nos, todavia, que não será toda a vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá a necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que determinaria a co-autoria (Vicente Greco Filho, *Tóxicos – Prevenção e Repressão – Comentários à Lei nº 6.368/76* acompanhados da Legislação vigente e de referência jurisprudencial, São Paulo, Saraiva, 5ª ed., p.104).

No caso, o vínculo associativo e a divisão de tarefas não estão bem caracterizados, pela falta de provas sobre isso, não bastando a simples situação

Logo, a conduta não está acobertada por causa excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, restando bem caracterizada a prática do delito.

Por tais motivos, a pretensão punitiva procede.

Passo à dosimetria.

Nessa tarefa, cabe observar o critério trifásico (art. 68 do CP) e os princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

Nesse sentido, o Código Penal prevê que o patamar da pena deve ser “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (art. 59, caput).

Ademais, no tocante especificamente aos crimes previstos na Lei 11.343/06, vale lembrar que “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente” (art. 42).

Prevalece na jurisprudência que, por serem circunstâncias preponderantes e devido à vedação ao *bis in idem*, a natureza e a quantidade de entorpecente devem ser valoradas apenas na primeira fase da dosimetria e só podem ser usadas na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado se estiverem conjugadas com outras circunstâncias do caso concreto, que, unidas, caracterizem a dedicação do agente a atividades criminosas ou integração a organização criminosa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA OU DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. O tratamento legal conferido ao crime de tráfico de drogas traz peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos – necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas – para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

3. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

4. No julgamento do RE n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese n. 712), o STF fixou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes não podem ser utilizadas em duas fases da dosimetria da pena.

5. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do REsp n. n. 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese n. 712 do STF, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

6. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise dos vetores "natureza e quantidade de drogas apreendidas" para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

7. A natureza e quantidade das drogas apreendidas podem ser utilizadas, supletivamente, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, apenas quando esse vetor for conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 687.767/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.

4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria.

5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in

idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base.

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença. (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021)

O delito de tráfico de drogas é punido com pena de reclusão, de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto e a de detenção, em regime semiaberto ou aberto, conforme o montante aplicado (menor que 4 anos, maior que 4 anos e menor que 8 anos ou maior que 8 anos) e a presença ou não de reincidência e antecedentes (art. 33, caput e §2º, do CP, Súmulas 269 e 440 do STJ e Súmulas 718 e 719 do STF).

A pena de multa é calculada em dias-multa, sendo, no mínimo, de 10 e no máximo de 360 dias-multa (art. 49 do CP), segundo o critério trifásico previsto no art. 68 do CP.

O valor do dia-multa não pode ser inferior a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, devendo ser considerada a situação econômica do réu (art. 60 do CP).

Na primeira fase, quanto aos antecedentes, verifica-se que os acusados são primários (fls. 659/660, 620/621 e 650).

Em particular, o acusado Valdinei possui condenações transitadas em julgado para a Defesa em 28/10/2020 (data do fato: 14/11/2017); em 17/07/2018 (data do fato: 23/11/2017) (fls. 625/630). Por sua vez, o acusado Júnior possui condenação transitada em julgado para a Defesa em 09/08/2021 (data do fato: 23/10/2018). (fls. 652/653).

Conforme o entendimento jurisprudencial, as condenações por fatos posteriores ao descrito na denúncia não caracterizam antecedentes e condenações antigas podem ser valoradas negativamente porque os antecedentes não se sujeitam ao prazo depurador de 5 anos aplicável à reincidência (art. 64, I, do CP)

A jurisprudência atual desta Corte, sedimentada no Enunciado de Súmula 444, veda às instâncias inferiores valorar negativamente a pena-base em função de inquéritos ou processos em curso, sem trânsito em julgado, em respeito ao princípio da presunção de não culpa. Ainda, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não é possível considerar a condenação transitada em julgado, correspondente a fato posterior ao narrado na denúncia, para valorar negativamente antecedentes, conduta social ou personalidade do agente. Entrementes, plenamente viável que a condenação por fato anterior à infração penal em processo de dosimetria, mas com trânsito em julgado superveniente a ela, seja utilizada como circunstância judicial negativa. (HC 443.678/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 26/03/2019)

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. (HC 433.543/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018)

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-

se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. (RE 593818, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020)

Portanto, tais acusados são primários, já que as condenações mencionadas se referem a fatos ocorridos depois daquele da denúncia, não caracterizando antecedentes. Assim, as condenações mencionadas devem ser desprezadas.

Quanto às demais circunstâncias judiciais (culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade do ato praticado; conduta social e personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e comportamento da vítima), não devem ser valoradas negativamente, pois inexistem peculiaridades fáticas aptas a justificar a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, ainda de acordo com a jurisprudência, "Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente" (REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021)

Consequentemente, a pena deve partir do mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da menoridade relativa quanto aos acusados Anderson e Juliano, visto que eles nasceram em 20/11/1998 e 29/04/1999 (art. 65, I, do CP), que, contudo, não repercute na dosimetria, uma vez que a pena se encontra no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Consequentemente a pena não se altera.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

Presente a causa de diminuição de 1/6 a 2/3 prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, considerando que o acusado é primário e inexistente comprovação de seu envolvimento em organização criminosa ou atividades criminosas, não bastando a quantidade de droga isoladamente para afastar o redutor. Sobre o assunto:

1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. (RHC 138117 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2021 PUBLIC 06-04-2021)

Esta Corte vem decidindo que a quantidade de entorpecentes apreendidos, isoladamente não legitima o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, se dissociada de outros elementos de prova, para atestar que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa" (AgRg no AREsp 1636928/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020)

Assim, inexistindo razões para maior rigor, cabe aplicar a maior fração de diminuição, ou seja, 2/3, o que resulta em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Logo, torno definitiva a pena em: 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

Pelo montante, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial aberto (art. 33, §2º, c, do Código Penal).

Os acusados fazem jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que a pena não supera 4 anos, ele é primário e não

cometeu o crime com violência ou grave ameaça a pessoa (art. 44 do CP). Na condenação superior a 1 ano, a substituição pode ser feita por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (art. 44, §2º, do CP).

Considerando que a sanção penal deve cumprir função pedagógica e social, cabível a aplicação de duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 01 salário-mínimo, a entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo juízo da execução, e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em estabelecimentos voltados à assistência social, saúde, ensino e congêneres ou em programas comunitários, a critério da unidade gestora e na forma a ser definida pelo juízo da execução (arts. 43, I e IV; 45 e 46 do CP; e art. 483 das NSCGJ).

Fica prejudicada a aplicação da suspensão condicional da pena (art. 77, III, do CP).

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para:

I- condenar ANDERSON JÚNIOR DA SILVA FERREIRA, FELIPE DA SILVA GOMES, VALDINEI MARCOS DIAS VALE, JULIANO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVAe JÚNIOR JOSE RAMOS à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06; e SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 01 salário-mínimo, a entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo juízo da execução, e prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas em estabelecimentos voltados à assistência social, saúde, ensino e congêneres ou em programas comunitários, a critério da unidade gestora e na forma a ser definida pelo juízo da execução; e

II- absolver os referidos acusados da acusação de prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06.

Por não mais interessar ao processo, autorizo a destruição do entorpecente apreendido (art. 72 da Lei 11.343/06 e art. 524-A das NSCGJ). Comunique-se à autoridade policial responsável, preferencialmente por meio eletrônico (art. 524-A, §2º, das NSCGJ). Serve a presente como ofício.

Custas pelos réus, observada a gratuidade de justiça.

O acusado VALDINEI MARCOS DIAS VALE responde ao processo preso por outro juízo, não sobrevivendo motivos para sua segregação cautelar no presente. Portanto, ele faria jus ao direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não devesse ficar preso (art. 387, §§1º e 2º, do CPP).

Os demais acusados respondem ao processo em liberdade, não sobrevivendo motivos para suas segregações cautelares. Portanto, eles fazem jus ao direito de recorrer em liberdade, salvo se por outros motivos deva ficar preso (art. 387, §§1º e 2º, do CPP).

Decorrido o prazo recursal, expeça-se certidão de honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 15, III, da Constituição e art. 398 das NSCGJ), o mandado de prisão e, após seu cumprimento, a guia de recolhimento definitiva (art. 467 a 474 das NSCGJ), bem como calcule-se a multa, intimando-se as partes para se manifestarem (arts. 479 a 483 das NSCGJ).

Expedida a guia, ela deverá ser encaminhada ao Juízo da Execução mediante lançamento da movimentação "processo findo", com a situação "suspense" (art. 468, §3º, das NSCGJ), certificando-se nos autos.

Após, nada mais restando a deliberar, archive-se, fazendo-se as anotações necessárias no sistema informatizado (art. 184 das NSCGJ).

Intime-se.

José Bonifacio, 07 de novembro de 2022.

MARGEM DIREITA